

1500222-14.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2048727/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23132280 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1368/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2048727 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500222-14.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500222-14.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2048727/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23132280 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 1368/22/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2048727 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2048727/2022 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SILVA MASSAGRANDE e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

RAFAEL SILVA MASSAGRANDE e RÔMULO DE ANDRADE REY MIGUELEZ, qualificados respectivamente às fls. 15 e 14, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, agravado pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", também do Código Penal, sob a acusação de que, na tarde de 19 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30m, na residência situada na Rua Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, n.º 460 - Bairro Parque Três Marias, nesta cidade e comarca, agindo em concurso tanto na ideação quanto na execução, traziam consigo e guardavam em comunhão de esforços e sob a posse comum, para o fito de entregarem a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, drogas, consistindo na massa líquida total de quinze gramas e vinte e nove decigramas (15,29g) da droga cocaína em pó (soma dos itens 1, 2 e 3, fls. 22/38), cinco gramas e sessenta e cinco decigramas (5,65g) da droga crack - cocaína sob a forma petrificada - além de

vinte e nove gramas e noventa e dois decigramas (29,92g) da droga Cannabis sativa L- popularmente conhecida como maconha -, todas substâncias determinantes de dependência física e psíquica, consoante testificam auto de constatação (fls. 22/38), o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e o laudo de exame químico-toxicológico que oportunamente se entranhará (requisitado a fls. 21).

Consta na denúncia que encontrava-se a cocaína parte sob a forma de pó branco de granulometria fina dividida em quatro (04) porções individuais, acondicionadas em microtubos plásticos e cinco (05) porções embaladas em invólucros plásticos, além de uma (01) porção maior a granel em invólucro plástico, e parte sob a forma de material sólido petrificado repartido em vinte e oito (28) pedras de crack embaladas em invólucros plásticos fechados por nó, prontos para comercialização no varejo a terceiros consumidores.

É da exordial que, por sua vez, a maconha encontrava-se dividida em quatorze (14) unidades constituindo dez (10) tiras e outras quatro (04) porções menores, igualmente destinadas à venda no varejo.

Versa a inicial que as drogas destinavam-se à mercancia ilícita, conforme se depreende de sua quantidade, variedade e forma de apresentação, do dinheiro apreendido e da tentativa de fuga impedida por policiais militares que, em patrulhamento de rotina, depararam com o réu RÔMULO, do lado de dentro do portão do imóvel supracitado, entregando algo a um indivíduo não qualificado e, ao perceberem a presença dos policiais, a pessoa desconhecida empreendeu fuga ao passo que RÔMULO tentou trancar o portão para impedir a abordagem pelos policiais militares, sendo, entretanto, detido no quintal do imóvel e, na sequência, mais no fundo do quintal, o réu RAFAEL foi também abordado e detido quando tentava arremessar por cima do muro uma sacola plástica contendo as variadas drogas supramencionadas (porções individuais e maiores de cocaína, crack e maconha). Em revista pessoal, descobriu-se que RÔMULO tinha consigo a quantia de R\$120,00 (cento e vinte reais) e RAFAEL a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Segundo a denúncia, insta salientar que os réus praticaram o crime em ocasião de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, internacional e nacionalmente reconhecida (Decreto Legislativo Federal n. 6, de 20 de março de 2020, e Decreto Estado de São Paulo n. 64.879, da mesma data), a qual causa emergência de saúde pública.

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva (fls. 97/99, 125/126 e 127/128).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 122/124), os réus foram pessoalmente notificados (Rafael às fls. 165; e Rômulo às fls. 166) e apresentaram defesa preliminar, Rafael por intermédio de defensor constituído (fls. 170/173) e Rômulo por intermédio da Defensoria Pública (fls. 178/179).

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (fls. 181/182) e os réus foram devidamente citados (Rafael às fls. 216; e Rômulo às fls. 217).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e os réus foram interrogados.

Em Debates, o Ministério Público, entendendo provados os fatos imputados na denúncia, requereu a condenação. Salientou os depoimentos policiais, corroborados pela prova indiciária (quantidade, variedade e forma de apresentação da droga) e pelo laudo. Réu Rafael reincidente. Regime fechado. Incabível a substituição.

Já a Defesa de Rômulo requereu a absolvição, sustentando que o STF já entendeu que é preciso autorização para a entrada no imóvel, sob pena de nulidade da prova.

Considerando a quantidade e forma do dinheiro que estava com Rômulo, induz-se que não é oriundo do tráfico de drogas (notas de cem e vinte reais). Salientou a vestimenta do réu e o fato de ali residir, em local mais simples, e o baixo aluguel. Argumentou, ainda, que não se sabe o que foi entregue antes da abordagem e que o réu não teve contato com a droga apreendida.

A Defesa de Rafael argumentou que o processo é nulo, como dito pela Defensoria. A pessoa que correu, pela frente da casa, não foi abordada. Rafael foi pego no fundo da casa. Não houve autorização. Não há como se afirmar de quem era a droga, pois a habitação é coletiva e os dois afirmaram serem usuários de drogas. Requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que os réus cometeram o delito que lhes imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/62), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo do exame de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 22/28), pelas fotografias do réu Rômulo (fls. 30/42), pelo laudo do exame de lesão corporal realizado no réu Rômulo, que não constatou lesões de interesse médico-legal (fls. 43), pelo laudo do exame de lesão corporal realizado no réu Rafael, que constatou "refere briga c/ terceiros. Escoriação região frontal D. Lesão leve" (fls. 44), pelos comprovantes de depósito judicial das quantias apreendidas (fls. 131/132), pelo laudo do exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nos materiais apreendidos (fls. 224/230) e, ainda, por toda a prova oral colhida, A autoria igualmente é certa.

O réu Rafael, ouvido em solo policial (fls. 05), declarou que "não mora no imóvel em que foi abordado e que teria ido até lá para usar drogas, sendo que policiais militares entraram no local e abordaram o interrogado e seu conhecido ROMULO que mora no local, mas o conhece apenas da rua, visto que costumam juntos consumir drogas. Relata que em seu poder não foi localizada droga alguma, apenas uma quantia em dinheiro que ganhou trabalhando como ajudante. Afirma que os policiais militares localizaram drogas na casa ao lado. Afirma ser apenas usuário de drogas, negando que pratique o tráfico. Não sabe informar o que ROMULO estava fazendo" (sic). Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Rafael disse que tem 35 anos, é chapeiro, trabalha com seu irmão e cunhado, já foi processado pelo mesmo artigo. É usuário de crack. Essa casa é conhecida como ponto de usuários de drogas. Mora com sua irmã mais velha, quando precisa, usa droga nessa casa. O dinheiro que tinha era para comprar a droga. Ali comprava, ali usava. Não chegou a comprar droga para usar, estava esperando o rapaz que se apresenta como dono da casa, ele é que ia comprar droga para usarem. Essa droga apareceu apenas na delegacia, na casa não apresentaram sacola, dinheiro. Estava na sala assistindo TV, quando a polícia chegou.

O réu Rômulo, ouvido em solo policial (fls. 06), declarou que "aluga um quarto para morar no imóvel em que foi abordado. Alega que não entregou nada a qualquer pessoa pouco antes de ser abordado, mas que apenas teria aberto o portão para o dono da casa sair, sendo abordado quando fechava o portão. Em seu poder não foi localizado nada de ilícito, apenas uma quantia em dinheiro que ganhou vendendo reciclagem. Ao ser questionado se havia mais alguém na casa, afirmou que havia mais pessoas no fundo. Não presenciou a abordagem de RAFAEL, mas sabia que ele se encontrava no imóvel. Afirma ser usuário de drogas, mas nega envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Não presenciou o encontro de drogas" (sic).

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Rômulo disse que tem 22 anos, saiu do Rio de Janeiro para mudar de vida, é artesão e trabalha com reciclagem, assim estava sobrevivendo e residindo nessa residência, que não é uma casa abandonada, alugava um quarto por 50 reais por semana. Tinha conta de luz, de água. Já teve um tráfico, decidiu largar essa vida. Residiu na Praça Santa Terezinha. É usuário de droga, mas desconhece a origem da droga. Usa crack. Quem saía da residência era o dono da casa, ele é que entregou a chave do cadeado para o interrogando, para que trancasse. Logo em seguida, chegaram os policiais, não entendeu nada. Não os impediu de entrar, se quisesse teria trancado o cadeado. Perguntaram se tinha mais gente, respondeu que tinha. Pegou seu dinheiro e identidade. Informou que era catador de reciclagem, mostrou que tinha carrinho de reciclagem. Não quiseram ouvir. Foram para os fundos da casa, onde pegaram Rafael, voltaram com uma droga desconhecida. Foram para o hospital e depois para a delegacia, estava com uma nota de cem e outra de vinte reais. Rafael

passava lá de vez em quando, mas não morava na casa. Ninguém correu para dentro. Estava dentro da residência. Do lado de dentro estava trancando o portão. Rafael estava na sala no fundo da casa. Chegaram, apontaram a arma para ele, levantou a mão, revistaram-no. Mandaram sentar no sofá, perguntaram se tinha mais alguém, disse que sim.

As testemunhas Charlem e Jocélio, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 03), relataram que "efetuava patrulhamento de rotina quando deparou-se com o indiciado ROMULO, do lado de dentro do portão do imóvel de número 460, situado na Rua Dr Adolfo Bezerra de Menezes, Terra Nova, entregando algo a um indivíduo não qualificado, sendo certo que, ao perceberem a presença da guarnição, aquele indivíduo desconhecido empreendeu fuga, enquanto ROMULO tentava trancar o portão, sendo impedido pelos policiais militares. Ato contínuo, a guarnição ingressou no quintal do imóvel e deteve ROMULO, tendo, na sequência, mais no fundo do quintal, abordado e detido o indiciado RAFAEL que tentava arremessar por cima do muro uma sacola plástica. Ambos foram submetidos à revista pessoal, sendo encontrado em poder de ROMULO a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) e com RAFAEL a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais). Já na sacola plástica que RAFAEL tentava dispensar, foram localizados 4 (quatro) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de crack, 5 (cinco) papелotes, uma porção a granel de cocaína e 14 (quatorze) porções de maconha, sendo 10 (dez) em tiras e 4 (quatro) em porções menores. Questionados sobre os fatos, RAFAEL alegou que aquelas drogas seriam destinadas ao uso dele e de ROMULO, nada informando acerca do dinheiro. Já ROMULO apenas informou que o dinheiro seria fruto de reciclagem" (sic).

Em juízo o policial Charlem disse que estavam em patrulhamento de rotina. Três indivíduos estavam no portão, um deles tentou passar algo para uma pessoa desconhecida. Foram abordar, um deles fugiu. Rômulo tentou fechar o portão, Rafael correu para os fundos da residência, quando foi abordado. Foi o outro soldado quem viu Rafael jogar a sacola e contou-lhe. Confirmou que viu Rômulo entregar algo para o terceiro que fugiu. Rômulo tentou trancar o portão. Negaram a venda, Rafael disse que a droga era para consumo, não para a venda. Admitiram a posse da droga para consumo, os dois. O local é uma casa abandonada, a que vários moradores de rua tem acesso. Não viu Rômulo em atividade ilícita, viram ele entregar algo a uma pessoa desconhecida, não pode afirmar que era droga. Não conhecia nenhum dos réus. Foi a primeira vez que os abordou. Rafael estava como uma pessoa normal, de bermuda e sem camisa. Não se recorda se tinha a aparência de usuário de droga.

Em juízo o policial Jocélio disse que estavam em patrulhamento quando observaram o Rômulo, em frente a uma residência, entregando algo para um morador de rua. Tentaram fazer a abordagem de ambos, mas o morador de rua correu. Abordaram Rômulo. Ele tentou entrar e trancar o portão com o cadeado, mas não conseguiu. Um indivíduo correu para dentro da residência, que é uma casa abandonada, ocupada por várias pessoas. Rômulo tinha 120 reais, que ele disse ser do seu trabalho de reciclagem. Rafael estava no canto do muro, que é muito alto, e tentou dispensar uma sacola, mas ficou presa no muro. Na sacola tinha drogas diversas, maconha, crack e cocaína. Rafael disse que a droga era para uso próprio de ambos. Rômulo disse desconhecer a droga. Rômulo estava entregando algo ao morador de rua, mas ele fugiu. Foi a primeira vez que abordou os réus. Não se recorda a aparência de Rafael no dia. Viu o momento em que Rafael dispensou a sacola, mas não caiu na residência vizinha. Com o Rafael havia 60 reais, mais 121 reais na sacola. Rômulo tinha uma nota de cem e outra de vinte, que disse ser da reciclagem. Rafael não deu a origem do dinheiro. Eram notas diversas. Na sacola também em notas diversas. Como se vê, não há a menor dúvida de que os réus praticaram o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram três pessoas, dentre elas o réu Rômulo, que do portão do imóvel entregou algo para um indivíduo desconhecido, morador de rua, despertando suspeita. Assim que se aproximaram, o morador de rua fugiu e um deles correu para o interior da residência. O réu Rômulo tentou trancar o portão, mas foi abordado.

Em seguida, os policiais militares adentraram o imóvel e, no quintal, detiveram Rômulo e em seguida Rafael, que foi visto pelo policial que foi em seu encalço tentando arremessar uma sacola plástica por cima do muro que cercava o imóvel. Em revista pessoal, os policiais localizaram com os réus o dinheiro apreendido. Já na sacola plástica que o réu Rafael estava tentando lançar pelo muro, acharam 01 (uma) porção à granel de cocaína, 09 (nove) porções individuais de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de crack e 14 (quatorze) porções de maconha).

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu Rafael declarou que estava no local para usar drogas e negou a mercancia ilícita de entorpecentes.

Já o réu Rômulo, alegou que não entregou nada para qualquer pessoa antes da abordagem e que estava apenas abrindo o portão para uma pessoa sair do imóvel, mas assim que foi fechá-lo, foi abordado. Declarou que o dinheiro localizado consigo era proveniente do serviço de reciclagem e, por fim, também negou a prática do tráfico de drogas.

Em juízo o réu Rafael manteve sua versão de que estava no local para usar drogas, afirmando que nada de ilícito foi encontrado consigo. Já o réu Rômulo disse que não passou nada para ninguém, mas sim recebeu, a chave do cadeado, do dono da casa, que saía do local.

Os policiais foram firmes e coesos em suas declarações e confirmaram como se deu a dinâmica dos fatos, narrando com detalhes como ocorreu a abordagem dos réus e apreensão das drogas. Indicaram que viram o réu Rômulo entregando algo para terceiro, morador de rua, bem como que o réu Rafael tentou lançar as drogas por cima do muro.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, como já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os policiais não tinham razões para incriminar os réus, que sequer conheciam. A tese auto-defensiva seria facilmente corroborada pelo dono da casa, mas não foi. Além disso, a prova demonstrou que o terceiro que fugiu recebeu algo de Rômulo, não entregou. Some-se a isso o fato de que se fosse o dono da residência, apenas saindo da casa, não teria porque fugir dos policiais.

A sacola com as drogas estava com Rafael, que fugiu para os fundos da residência ao

ver a polícia, mas inicialmente estava junto com Rômulo.

Sendo assim, a tese defensiva de irregularidade da entrada dos policiais na residência do réu não deve prosperar.

Ainda que os policiais tenham entrado na casa do réu sem estarem devidamente autorizados, diante da situação flagrancial de crime, a irregularidade se desfez. A legalidade da ação policial encontra respaldo em decisão do Superior Tribunal de Justiça: "Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. Precedente." (HC 222.173/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22.11.2011, publicado em 1.12.2011).

A autoria delitiva é irrefutável.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Os fatos deixam claro que os réus traziam consigo e guardavam os entorpecentes apreendidos, portanto, desnecessário terem sido flagrados em ato de venda.

Nesse sentido: "Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação" (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

E, ainda que sejam usuários de entorpecentes, o que não se duvida, isso não descaracteriza o crime.

"O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga" ("Tóxicos Prevenção Repressão", Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119).

A materialidade do crime está igualmente comprovada, pois tanto o laudo de constatação provisória (fls. 22/28), quanto o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 224/230), confirmou a ilicitude das substâncias encontradas com os réus, identificadas como cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC).

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (15,29 g de cocaína em sua forma pura - pó branco de granulometria fina, 5,65 de cocaína em sua forma petrificada - crack e 29,92g de maconha), a forma de acondicionamento (a cocaína distribuída em uma porção à granel e 09 porções individuais, o crack fracionado em 28 pedras e a maconha disposta em 14 porções), as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais que realizavam patrulha de rotina quando visualizaram o réu Rômulo na porta de um imóvel entregando algo para terceiro, tendo este empreendido fuga, sendo que em seguida o réu Rômulo tentou trancar o portão, mas os policiais adentraram o local e puderam visualizar o réu Rafael, que corria, tentando arremessar uma sacola plástica pelo muro do imóvel, ocasião em que os réus foram detidos e a droga foi localizada no interior da sacola plástica) e a quantia apreendida (R\$ 301,00, às fls. 131/132), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

Com a inflação e o preço das drogas, o fato de algumas notas serem de maior valor não descaracteriza o crime.

Entendo que não está presente a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o delito não foi cometido prevalecendo-

se da calamidade pública.

Ao réu Rafael, em razão da sua reincidência e maus antecedentes, evidente que se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual não se reconhece o privilégio. Já com relação ao réu Rômulo, nota-se que não há nos autos notícias de que tenha passagem criminal, nem mesmo durante a adolescência, nem há provas de que se dedique a atividades criminosas com habitualidade ou integre organização criminosa, sendo de rigor o reconhecimento das benesses previstas no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Assim sendo, de rigor a condenação dos réus, devendo o réu Rafael ser responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e o réu Rômulo ser responsabilizado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a acusado Rômulo não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 90 e 220/221), bem como noto que o réu Rafael possui maus antecedentes (processo n.º 27844/2008 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 03, às fls. 86; processo n.º 15137/2009 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 04, às fls. 86; e processo n.º 6376/2009 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 06, às fls. 87, todos eles extintos pelo cumprimento em 25/11/2020, conforme informações complementares de fls. 84). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, variedade e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, é de se considerar a variedade de droga apreendida (cocaína, crack e maconha), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que os réus estavam lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros, bem como a natureza deletéria de uma das drogas, apreendidas, cocaína em forma de crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas. Assim, fixo a pena-base do réu Rômulo em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, bem como fixo a pena-base do réu Rafael em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A exasperação da pena-base se mostra necessária em razão da natureza de uma das drogas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa” (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida”. (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator MARCO DE LORENZI. São Paulo, 4 de julho de 2013).

E ainda:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se configura constrangimento ilegal o fato de as instâncias ordinárias levarem em consideração, para exasperar a pena-base do paciente, a elevada quantidade de drogas apreendidas (in casu, 322,08 g de maconha e 11 selos de LSD), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, HC n. 314.102/TO, Min. Rel. Ribeiro Dantas, j. em 12/04/2016 – destaquei).

Ausentes agravantes ao réu Rômulo.

Com relação ao réu Rafael, tratando-se de reincidente (processo n.º 16921/2009 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 85, cuja extinção da punibilidade se deu em 25/11/2020, conforme informações complementares de fls. 84; vale destacar que, ainda que se leve em consideração o período em que cumpriu pena em livramento condicional – datado de 24/03/2017, conforme fls. 84 – a condição de reincidência permanece, porquanto da data em que foi liberado até a data do crime, não se passaram mais de cinco anos), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que passe a ser 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Por fim, com relação ao réu Rômulo, em razão do que preceitua o § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o réu é primário, de bons antecedentes, inexistindo notícia de que integre organização criminosa ou prova de que vinha traficando há tempos, reduz a reprimenda em 2/3, para que fique em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Com relação ao réu Rômulo, considerando a decisão proferida no HC n.º 596.603, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 08 de setembro de 2020, bem como à vista dos elementos dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos contidos nos incisos I (pena não superior a quatro anos e crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais que não são desfavoráveis) do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual tem o réu direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o

artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal.

Inviável a suspensão condicional da pena, porquanto a pena restritiva de direitos é ao réu mais benéfica.

Em caso de revogação do benefício, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, pois há de se considerar a variedade de drogas, que aumenta a culpabilidade do réu, bem como a natureza deletéria do crack traficado, ambas já explicitadas na primeira fase da dosimetria da pena.

Já com relação ao réu Rafael, deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal, pois há de se considerar a variedade de drogas, que aumenta a culpabilidade do réu, bem como a natureza deletéria do crack traficado, ambas já explicitadas na primeira fase da dosimetria da pena.

A fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta é idôneo quando baseado nas circunstâncias judicial (CP, art. 59) e levando-se em consideração, ainda, com preponderância sobre o referido dispositivo, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (Lei 11.343/06, art. 42).

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime inicial, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu é reincidente e o regime inicial para o cumprimento de sua pena continua sendo o fechado.

Nesta toada, não concedo ao acusado Rafael o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente – precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados, na medida em que ele se dedicava intensamente às atividades espúrias.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90

(noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica dos réus a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-os no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR:

(I) RAFAEL SILVA MASSAGRANDE, filho de Valdecir Aparecido Massagrande e Marlene Aparecida Silva, RG n.º 42.965.593, nascido aos 31 de janeiro de 1987, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo; e

(II) RÔMULO DE ANDRADE REY MIGUELEZ, filho de Roberto Rey Miguelez Júnior e Aline Lopes de Andrade Miguelez, RG n.º 75.054.041, nascido aos 25 de maio de 1999, natural de Nova Iguaçu/RJ, como incurso no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade imposta somente ao réu Rômulo, por duas penas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal, pelo período da pena corporal, a ser fiscalizado pelo juízo da execução (CP, art. 55), e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente à entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada no Juízo da Execução, com fundamento no artigo 44, §2º e artigo 45, §1º, ambos do Código Penal. Com relação ao réu Rômulo, em razão da pena aplicada, apelo em liberdade. Expeça-se, em seu favor, alvará de soltura clausulado.

Recomenda-se a manutenção do réu Rafael onde se encontra recolhido em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu Rafael no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condeno os réus a arcarem, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. Com relação ao réu Rômulo, a exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência. Já com relação ao réu Rafael, indefiro o pedido de gratuidade formulado na defesa preliminar de fls. 170/173, pois, embora a Defesa tenha sido devidamente intimada para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência (fls. 184), não o fez.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu (depósitos judiciais às fls. 131/132), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA